

1503853-69.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... por guardas civis, o que configura tráfico e não uso de drogas.

Assim, uma vez que o réu foi surpreendido tendo consigo substância entorpecente, não se pode falar em guarda para consumo próprio, com a consequente desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, mas sim em tráfico ilícito.

Certo é que, a só quantidade de droga, ainda que razoável, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1503853-69.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503853-69.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIVELTON SILVERIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Elivelton Silverino, qualificado nos autos na fl. 20, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 15/fevereiro/2022, por volta das 15h10, na Rua Quintino Bocaiuva, altura do nº 161, Sé, nesta comarca, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 104g de cocaína, em 15 porções e 71,4g de tetrahydrocannabinol (THC), em 65 porções na forma de maconha e 58 na forma de haxixe, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na denúncia que, o réu trazia consigo uma mochila contendo as drogas supramencionadas, visando comercializá-las, tendo se dirigido à região da Praça da

Sé; guardas civis metropolitanos o avistaram em atitude suspeita, demonstrando demasiado nervosismo e desconforto com a presença da guarnição; após atender ao telefone, o acusado caminhou em direção à Rua Quintino Bocaiuva, sendo acompanhado pelos guardas civis, que realizaram sua abordagem; em revista pessoal, as drogas foram localizadas na mochila do denunciado, bem como a quantia de R\$824,00 em espécie; questionado informalmente, ele disse ter recebido certa quantia de dinheiro para transportar a mochila contendo as substâncias e o numerário. A denúncia (fls. 106/107) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 01/101), sendo a peça acusatória recebida em 24/março/2022 (fls. 108/110). Após a necessária notificação/citação (fl. 120), o réu apresentou resposta à acusação (fl. 124). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas (áudio - audiência virtual sistema Teams) e o denunciado interrogado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas suas considerações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição por falta de provas; em pedido subsidiário, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, iniciando-se o cumprimento da pena no regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Laudo de Constatação Prévia encontra-se nas fls. 42/45; o de Exame Químico Toxicológico nas fls. 127/128 e o Auto de Exibição e Apreensão das substâncias entorpecentes está nas fls. 12/13.

É o relatório.

Decido.

Ao término da instrução, verificou-se que os fatos narrados na exordial restaram comprovados, razão pela qual a ação deve ser julgada a favor da Justiça Pública. Interrogado em Juízo, o acusado Elivelton Silverino, 28 anos, confessou a autoria delitiva; estava em São Paulo há pouco tempo; uma moça que conheceu ofereceu o serviço: fazer o transporte da droga para uma determinada pessoa; receberia pelo serviço R\$ 500,00 (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A testemunha Vanderlei Rocha de Matos, guarda civil metropolitano, relatou que, em patrulhamento de rotina pela região dos fatos, momento em que se deparou com o réu; chamou atenção por que do local onde ele estava (parte de cima da escadaria), ele vestia uma camiseta de time de futebol italiano; ele olhou para a viatura e desceu a escada, subindo novamente logo em seguida; entendeu que o réu estava evitando a aproximação; permaneceu à distância o observando, momento em que ele atendeu o celular e saiu andando rapidamente da praça portando uma bolsa; interceptado, dentro da bolsa que portava, encontrou entorpecentes; arguido, ele confessou a traficância, dizendo que entregaria aquilo para alguém; havia cerca de 150 papелotes de cocaína, além de 60 de maconha e haxixe (áudio sistema SAJ).

O depoente Douglas Henrique Carneiro, também guarda civil, ratificou, na íntegra, o depoimento do colega de farda, em especial, o momento em que o réu, ao ver a viatura, mudou de direção; ao vê-lo saindo da feira do rolo resolveu ir atrás dele; abordado, com ele encontrou entorpecentes e dinheiro; as drogas eram cocaína e maconha e estavam dentro de uma bolsa; lembra-se que o réu disse que recebeu dinheiro para transportar a droga (áudio sistema SAJ).

Como se vê, a oitiva das testemunhas presenciais, somadas a confissão do réu, ao Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Prévia e Exame Químico Toxicológico, tudo aponta no sentido de que a versão apresentada pela acusação é a verdadeira, eis que encontra simetria com as demais provas dos autos. Com sua conduta, o réu se enquadra em, pelo menos, um verbo do tipo previsto no artigo 33 da lei especial: trazer consigo.

Destarte, verifica-se que a ação penal procede.

De fato, os depoimentos dos policiais foram claros, serenos e seguros, dando conta da apreensão em poder do acusado, de razoável quantidade de substância entorpecente, o suficiente a denotar o intuito da traficância.

A materialidade está estampada no Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), no Auto de Constatação Prévia (fls. 42/45) e no Exame Químico Toxicológico (fls. 127/128).

Este último demonstra que as substâncias apreendidas realmente eram cocaína e maconha.

Em que pese à insurgência da Defesa, a traficância restou devidamente caracterizada e comprovada.

Como visto, os depoimentos dos guardas civis ouvidos em Juízo são coerentes e harmônicos e traduzem a certeza de que o réu, efetivamente, trazia consigo, dentro de uma mochila, razoável quantidade de cocaína e maconha, quando foi flagrado pelos agentes.

Portanto, restou claro que os guardas civis prenderam o acusado em flagrante em plena conduta típica, apreendendo em seu poder toda a cocaína e maconha encontrada. Bem sabemos, como já dito acima, que incide nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aquele que é detido com expressiva quantidade de substância tóxica.

No caso concreto, a droga estava sendo trazida, para entrega a consumo de terceiros, pelo acusado em plena via pública, instante em que foi abordado por guardas civis, o que configura tráfico e não uso de drogas.

Assim, uma vez que o réu foi surpreendido tendo consigo substância entorpecente, não se pode falar em guarda para consumo próprio, com a consequente desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, mas sim em tráfico ilícito.

Certo é que, a só quantidade de droga, ainda que razoável, não define, por si só, a condição de traficante. Mas no presente caso, verifica-se que o réu foi flagrado trazendo consigo toda a cocaína e maconha apreendida dentro de uma mochila.

É sabido que se tem reiteradamente decidido que para a caracterização do delito previsto no artigo 33, não se faz necessário seja o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Tratando-se de crime de mera conduta, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, não importa a modalidade, forçoso reconhecer-se à configuração do crime em tela.

Ademais, por importante, mister se faz atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida (71,4g de maconha e 104g), o local (dentro de uma mochila) e as condições em que se desenvolveu a atividade delituosa (guardas civis avistaram o acusado em atitude suspeita e ele, ao avistar a guarnição, apresentou nervosismo e desconforto, razão pela qual foi abordado e as drogas localizadas).

Outrossim, não há que desmerecer os depoimentos dos guardas - ouvidos como testemunhas - tão só pelo fato de serem eles integrantes da Polícia.

Tal significaria preconceito odioso e inaceitável, caracterizando mesmo clara discriminação profissional que não tem qualquer respaldo jurídico.

Observe-se que, a Defesa nada comprovou contra a honradez e honorabilidade dos guardas ouvidos como testemunhas neste processo, nem mesmo que tivessem eles qualquer razão escusa para pretenderem prejudicar o acusado.

Assim, seus depoimentos hão de ser prestigiados, em especial porque apresentam contornos de verossimilhança, estão conforme o conjunto das provas e, ademais, como já dito, são coerentes entre si, formando um todo harmônico e lógico.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar - Justiça Gratuita - Isenção deverá ser buscada na fase de execução do julgado - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas - Acusado surpreendido trazendo consigo drogas de nefastas consequências para imediata distribuição - Depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais responsáveis pela diligência - Validade - Desclassificação para uso - Não acolhimento - Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito mercantil - Pena inalterada - Redutor negado, mercê da comprovada reincidência - Regime mantido em razão da reincidência e da gravidade da conduta - Inviável, por idênticos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Apelo improvido.(TJSP; Apelação Criminal 1514762-44.2020.8.26.0228; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Condenação - Recursos da defesa e

ministerial - Autoria e materialidade delitivas demonstradas - Confissão - Depoimentos coesos dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante - Validade - Condenação mantida - Penas readequadas - Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 - Regime fechado de rigor - Inviável substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.(TJSP; Apelação Criminal 1500898-97.2019.8.26.0510; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 14/12/2020)

Não se pode negar valia aos depoimentos dados pelos guardas civis nestes autos, pois, repita-se, produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.

Como já dito, não há sequer sugestão de que tivessem eles o mínimo interesse em incriminar o acusado injustamente, mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denúncia caluniosa. Ante o exposto, conclui-se que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o bastante a embasar a expedição de um édito condenatório.

O réu realizou conduta antijurídica que se subsume em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art. 65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Cód. Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 2ª ed. Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Prevê o artigo 42 da Lei nº. 11.343/06: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu é primário (fls. 46/47).

Sua culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade de sua conduta, no caso, é de média intensidade.

Sua personalidade e conduta social hão de ser tidos por média intensidade.

Atento, ainda, ao motivo do delito - qual seja, o ânimo de auferir lucro, já que se dispôs a trazer a droga no meio da rua - bem como, atento às circunstâncias e funestas consequências da infração, que degrada a pessoa e compromete o tecido social e, em especial, considerando a quantidade de substâncias entorpecentes que o acusado trazia consigo, com os malefícios de todos conhecidos, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos e de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, uma vez que a pena foi fixada em seu mínimo legal.

Por fim, o acusado faz jus à causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da nova lei de entorpecentes, eis que é primário e possui bons antecedentes, devendo sua pena ser reduzida no patamar de 2/3 (dois terços), chegando-se a pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, a qual torno definitiva na ausência de

outras modificadoras.

Cada dia multa fica fixado no valor mínimo previsto na lei especial, dada a pouca fortuna do réu, dado que emerge dos autos.

Atento a primariedade do acusado, além da quantidade de pena imposta, fixo o regime aberto para cumprimento de pena.

Anoto que, este posicionamento, neste caso, partiu da necessidade de proporcionar ao réu uma nova oportunidade, pois não adianta somente castigar o indivíduo; retirá-lo do convívio da sociedade e de seus familiares, da possibilidade de conseguir sustentar-se e encarcerá-lo novamente gerará uma revolta; a descrença na justiça será enorme; sua não reinserção na sociedade fará com que acabe praticando novas infrações e, atolando ainda mais o sistema carcerário.

DECISÃO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVADEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar Elivelton Silverino, qualificado nos autos na fl. 20, incurso no artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, cada qual no valor mínimo legal, ante a pouca fortuna do condenado, dado emergente dos autos. Expeça-se alvará de soltura clausulado imediatamente.

Preenchendo o acusado os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, converto sua pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam, uma prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas a critério do Juízo das Execuções Criminais, mais pagamento de 10 (dez) dias multa.

Neste sentido:

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Apelo do Ministério Público desprovido - Quantidade de entorpecente apreendida que não pode ser considerada expressiva, razão pela qual a pena-base deve ser mantida no mínimo legal - Ausente prova de que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa - Cabível o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, com a redução da pena, em sua fração máxima (2/3), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - Viável a substituição da reclusiva por duas penas alternativas, consistentes em prestação de serviços comunitários e outra multa - Também deve ser modificado o regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP - Precedentes do C. STJ e do E. STF - APELO DO MP DESPROVIDO - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO para reduzir as penas a 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, bem como para modificar o regime para o aberto, substituindo-se a reclusiva por penas restritivas de direitos - Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1500317-90.2018.8.26.0551; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020)

Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, expor à venda e guardar 46 porções de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Depoimentos de policiais militares que efetuarão a prisão. Usuário surpreendido no momento da abordagem que afirmou ter adquirido entorpecente do réu. Validade e suficiência para a procedência da ação penal. Circunstâncias da prisão e modo de acondicionamento indicativos do intuito mercantil. Condenação mantida. PENA. Majorante referente à proximidade de igrejas e estabelecimentos de ensino que não pode ser mantida. Absoluta ausência de indicativos no sentido de que a traficância colocava em risco os seus frequentadores. Redução para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão da pena reclusiva em restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Imposição do regime aberto. Apelo defensivo parcialmente provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 0000271-94.2017.8.26.0557; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª

Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Nos termos do artigo 63, caput e §1º, da Lei 11.343/2006, determino, se for o caso, o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas armazenadas para contraprova, no prazo máximo de 30 dias, devendo a autoridade policial enviar termo da incineração.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que assistido pela Defensoria Pública.

P . I . C .

São Paulo, 24 de maio de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.